

1502308-59.2021.8.26.0628

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: DJALMA MOREIRA GOMES JUNIOR

Comarca: Itapecerica da Serra

Foro: Foro de Itapecerica da Serra

Vara: 4ª Vara

Data de Disponibilização: 16/08/2022

... para a configuração do crime de tráfico de drogas, na medida em que "... para configuração do crime de tráfico imputado ao réu, não se exige qualquer ato de tráfico, bastando que o agente traga consigo, tenha em depósito ou guarde a substância entorpecente, não se exigindo a traditio, para consumação do delito (RJTJSP vol. 97, página 512), salientando que eventual ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapecerica da Serra

Foro de Itapecerica da Serra

4ª Vara

Rua Major Matheus Rotger Domingues, 155, Itapecerica da Serra-SP - cep 06850-850

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1502308-59.2021.8.26.0628 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502308-59.2021.8.26.0628

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2320480/2021 - DEL.POL.ITAPECERICA DA SERRA, 21588008 - DEL.POL.ITAPECERICA DA SERRA, 4012/21/406 - DEL.POL.ITAPECERICA DA SERRA, 2320480 - DEL.POL.ITAPECERICA DA SERRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JHONATHAN APARECIDO DOS SANTOS e outro

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DJALMA MOREIRA GOMES JUNIOR

Vistos.

JHONATHAN APARECIDO DOS SANTOS e EDEGAR GABRIEL DA SILVA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, conforme os fatos narrados na denúncia à qual me reporto (fls. 110/112).

Oferecida a denúncia, esta foi recebida (fls. 117/120) e os réus devidamente citados.

Após a apresentação de defesas escritas (fls. 139/144 e 165/166), o recebimento da denúncia foi ratificado (fls. 183).

Durante a instrução foram inquiridas testemunhas e, ao final, interrogados os acusados.

Encerrada a instrução criminal, manifestaram-se as partes, em alegações finais orais.

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

Não há preliminar a ser apreciada.

E, no mérito, a ação penal deve ser julgada PALCIALMENTE PROCEDENTE, isso porque, terminada a instrução da causa, restou devidamente comprovado nos autos que apenas o acusado JHONATHAN praticou o delito lhe é imputado.

A materialidade da infração penal, bem como sua autoria, quanto ao réu JHONATHAN, são indúvidas, eis que comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), pelo boletim de ocorrência (fls. 08/10), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 11), pelo laudo químico toxicológico (fls. 136/138), que atesta pelos resultados positivos para cloreto de metileno/diclorometano, pelo relatório final (fls. 103/105), bem como pela prova oral nos autos produzida.

De fato, os Policiais Militares Jefferson de Souza Lombas e Fábio Palmeira Cruz, quando inquiridos em juízo, disseram que faziam patrulhamento de ROCAN quando visualizaram um veículo que aparentava ser de “uber”, com um passageiro no banco traseiro, ocasião em que resolveram realizar a abordagem. Um dos agentes ainda pontuou que o fato de o automóvel ser velho também motivou a abordagem.

Durante a abordagem encontraram as drogas apreendidas com o indivíduo que estava atrás, o réu JHONATHAN, o qual informou que estava levando as drogas para uma “rave” e que o motorista, ora acusado EDEGAR, tinha conhecimento dos fatos.

E a fala dos policiais, contra quem nada se levantou, foram harmônicas e isentas de contradições, se cotejadas com os depoimentos prestados, por eles, tanto em juízo quanto na fase inquisitorial, o que até se justificaria considerando o número de ocorrências que atendem os agentes da lei, merecendo pleno crédito.

Ressalte-se, por oportuno, que os policiais não estão impedidos de depor pela legislação processual pátria. E o fato de serem servidores comprometidos com a aplicação da lei, repressão e combate ao crime, não retira a força de suas palavras. Pelo contrário, suas palavras têm pleno crédito até que prova manifesta em contrário exclua a presunção.

Nesse sentido:

“Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes” (AgRg no HC 706.153/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021)

“De outro lado, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. A propósito: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e

HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 17/03/2016" (AgRg no HC 695.991/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDF), QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 17/11/2021)

"o Estado tem seus agentes concursados legalmente aptos a reprimir o crime e seus depoimentos somente podem ser afastados se demonstrada eventual irregularidade ou interesse particular na condenação do acusado, o que não se deu no caso em tela. Demais disso, as falas destes profissionais, que, escolhidos pelo Estado para desempenhar a nobre função de proteção da população, possuem fé pública, sendo seus depoimentos dignos de crédito e plena validade" (TJSP; Apelação Criminal 1500867-65.2021.8.26.0168; Relator (a): Edison Brandão; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Dracena - 3ª Vara; Data do Julgamento: 21/10/2021; Data de Registro: 21/10/2021)

"No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário. O mesmo raciocínio se aplica aos Guardas Municipais" TJSP; Apelação Criminal 1501314-54.2020.8.26.0567; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Sorocaba - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 23/07/2021; Data de Registro: 23/07/2021

A testemunha arrolada pela defesa, Maria Aparecida da Silva Gomes, quando inquirida em juízo disse que o réu EDEGAR trabalha de uber e que no dia dos fatos chegou a pedir carona para o acusado. Contudo, JHONATHAN acabou adentrando como passageiro.

O réu JHONATHAN, quando interrogado, disse que realmente estava levando as drogas. No entanto, EDEGAR não tinha conhecimento do fato e estava apenas prestando o serviço de "uber", malgrado o aplicativo estivesse desligado.

O acusado EDEGAR, ao ser interrogado em juízo, trouxe a mesma versão, esclarecendo que é motorista de "uber" e que no dia dos fatos estava trabalhando, sendo que pegou o passageiro com o aplicativo desligado para poder fazer um preço melhor.

Pois bem.

Com efeito, o direito penal, por se tratar de ultima ratio, opera com punições severas às condutas que violam os bens juridicamente tutelados, podendo culminar na restrição de liberdade do indivíduo violador da norma.

Assim, diante do seu caráter eminentemente protetivo/punitivo, a intervenção estatal, por meio da repressão penal, somente ocorrerá após o devido processo legal e desde que o estado, representado Poder Judiciário, por meio Magistrado, verificar a prova inequívoca da autoria e da materialidade delitiva.

Diferentemente do que ocorre na fase pré-processual, em que se prestigia o princípio in dubio pro societate, na fase endoprocessual o édito condenatório somente poderá ser proferido quando verificada a certeza do cometimento da infração penal.

E isso se dá porque, embora se pretenda a proteção do bem juridicamente tutelado, o direito penal também é instrumento para proteção do indivíduo/réu contra o Estado, resguardando-se, acima de qualquer outro direito, a dignidade da pessoa humana, que é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil (Constituição Federal, artigo 1º, inciso III).

Dessa forma, “na dúvida, de rigor o non liquet, ainda que, com isso, esteja-se correndo risco de brindar com imerecida absolvição aquele que fazia por merecer condenação, devendo-se privilegiar o princípio do in dubio pro reo”.

Assim, o acusado EDEGAR deve ser absolvido.

Por outro lado, em relação ao réu JHONATHAN, a imputação Ministerial é passível de acolhimento porque restou devidamente demonstrado pelas provas colhidas que o acusado, de fato, estava a praticar a traficância.

Isso porque está clara a prática do que traz o tipo previsto no artigo 33, “caput”, da Lei de Tóxicos, qual seja, o tráfico de entorpecentes, por parte do réu, na medida em que levava consigo drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ora, os entorpecentes eram levados pelo réu, que os detinha especialmente para o fim de cometer a traficância, conforme asseverado pelas testemunhas hoje inquiridas, o que fica reforçado ao se analisar o conjunto das provas e a confissão do acusado.

A propósito, o fato de o réu levar consigo os entorpecentes é suficiente para a configuração do crime de tráfico de drogas, na medida em que “... para configuração do crime de tráfico imputado ao réu, não se exige qualquer ato de tráfico, bastando que o agente traga consigo, tenha em depósito ou guarde a substância entorpecente, não se exigindo a traditio, para consumação do delito (RJTJSP vol. 97, página 512), salientando que eventual condição de usuário por si só não afasta a de traficante ...” (Apelação Criminal nº 990.09.083925-2, Relator Marco Antonio Marques da Silva).

Assim, diante dos elementos de convicção e das provas produzidas nos autos, não resta dúvida de que o proceder do acusado se amolda perfeitamente ao tipo penal descrito como tráfico de entorpecentes, sendo sua condenação quanto a esse delito medida criteriosa que se impõe, já que ausentes circunstâncias que excluam o crime ou os isentem de pena.

Isso posto e considerando o mais do que dos autos consta, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal e, via de consequência:

a) absolvo EDEGAR GABRIEL DA SILVA, qualificado nos autos, e o faço com fundamento no artigo 386, IV, do Código de Processo Penal e

b) condeno JHONATHAN APARECIDO DOS SANTOS, qualificado nos autos, como incurso artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06

Apurada a responsabilidade penal, atento às regras de fixação de penas estampadas nos artigos 59 e 60, do Código Penal, passo a dosar a pena de condenação, quanto ao réu.

Na primeira fase não há circunstâncias a serem sopesadas.

Na segunda fase, a atenuante da confissão espontânea fica compensada pela agravante da reincidência específica, a qual pode ser verificada na certidão de fls. 38/39.

E, na terceira fase, de aplicação da pena, aplico a causa de redução mencionada no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06, à razão de 2/3, já que o acusado em questão é tecnicamente primário e não é portador de Maus Antecedentes, sem haver nos autos prova de que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa.

Na terceira fase da dosagem, verifico que o acusado não tem direito à causa de redução mencionada no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06, porque esta regra não incide ao caso concreto.

Isso porque o réu é reincidente específico, o que demonstra que é contumaz na prática de crimes. Ademais, tais fatos demonstram que o acusado tem se dedicado a atividade criminosa, circunstância apta a afastar a possibilidade de aplicação da causa de redução em comento, notadamente ao se considerar que a condenação anterior é por crime idêntico ao tratado nos autos.

Portanto, o réu não faz jus à benesse referida, pois não se trata de debutante na prática de crimes.

Nesse sentido, verifique-se o seguinte trecho do excelente voto condutor prolatado pelo Excelentíssimo Desembargador Geraldo Wohlers, em v. acórdão que confirmou condenação proferida por este magistrado, na Comarca de Serrana:

“A diminuição hoje admitida pelo parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas não se mostra viável na medida em que se cuida de infração indicativa de alta periculosidade do agente. O propósito do legislador, certamente, não foi favorecer os traficantes de alto coturno. A mens legis da Lei nº 11.343/06 há de ter tido em vista, primordialmente, fornecedores ocasionais, que não denotam perseverança criminosa, hábito delinquencial ou gravíssimo comprometimento para a ordem social, a paz coletiva e a saúde da população em geral, virtudes certamente irreconhecíveis no imperdoável traficante de drogas que persevera nessa senda. Tanto, aliás, que o citado art. 33, § 4º, contém expressa referência, para fins de merecimento da redução condescendente, à exigência de que o agente “não se dedique às atividades criminosas”.

Sabe-se que em termos repressivos o ditame constitucional é o de desestimular com energia o comércio ilegal de drogas; logo, o benefício trazido pela nova lei de regência, editada sob o mote de tornar mais rigoroso o tratamento penal que incide sobre o traficante, conflita, quando aplicado de modo indiscriminado, com a Constituição da República. Há, além da quebra do princípio de isonomia entre os condenados por outros crimes (especialmente pelos classificados como igualmente hediondos) e os condenados por tráfico de drogas, uma violação às disposições constitucionais e aos tratados internacionais que obrigam o Poder Público brasileiro à repressão efetiva do narcotráfico. A inteligência útil e legítima da norma sob análise só pode ser feita à luz da Carta Política, e nesse passo se conclui que a mercê foi estabelecida para dar solução excepcional a situações excepcionais.

No âmbito desta Colenda Câmara, consignou o preclaro DES. LUIZ ANTONIO CARDOSO por ocasião do julgamento da Apelação Criminal nº 990.09.111160-0 (Comarca de Lucélia, j. em 25 de maio de 2010), que “essa causa de redução da pena deve incidir na excepcionalidade, em situações específicas, próprias, quando patente que o tráfico apurado cuidou-se apenas de um desvio na vida do réu, e não de uma contumácia, estilo, repetição de fato análogo, de uma rotina de proceder”.

A lei atual trouxe tratamento distinto para quem oferece droga a pessoa de seu relacionamento sem objetivo de lucro a rigor, traficante de entorpecentes: § 3º do mesmo artigo 33. Ora, também se reserva tratamento diferenciado no § 4º, pois o redutor se dirige a quem comete uma das condutas puníveis constantes do caput ou do § 1º do artigo 33 quando o agente atua sem ter o lucro por meta, sem intuito de comércio, sem adotar a odiosa e desagregadora propagação narcótica como meio de vida.

É assim que se deve considerar a exigência de “não se dedicar às atividades criminosas” (terceira figura dos pressupostos indispensáveis à concessão da benesse), porque quem procura obter vantagem financeira através do mercadejo de substância clandestina se propõe, claro, a exercer atividade criminosa: presta o torpe serviço para alguém, faz a deplorável intermediação para alguém, busca aumentar os recursos ilícitos de grupos ou organizações formadas à margem da lei

para custear investidas delituosas n'outros setores do submundo. Convenhamos ser fenômeno de extrema raridade o traficante que age solitariamente... Se se der outra interpretação ao dispositivo em apreço, de forma a alcançar todo e qualquer agente que preencha os demais requisitos, haverá incontornável discrepância com outras normas da mesma Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, como, por exemplo, a descrição típica de seu artigo 37 (mero informante)". (TJ/SP; Ap. 0003339-42.2011.8.26.0596; OJ 3ª Câmara de Direito Criminal: DJ 04/12.12) (destaquei)

Por tudo isso e se considerando sobremaneira que há indicativos suficientes de que se dedica a atividades criminosas, é de se afastar a incidência, em concreto, da causa de diminuição em tela.

Assim, chego, à pena definitiva de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, ao valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, atualizando-se consoante manda a lei.

O regime inicial do cumprimento de pena é o FECHADO, diante da gravidade do delito em questão, da pena aplicada e da dupla reincidência do acusado.

Vale mencionar, a propósito, a Carta de Florianópolis, de 12/08/2017, publicada no 1º Fórum Nacional dos Juizes Criminais, em que os seus integrantes, entre os quais este magistrado, deixaram assentado que "diante do recrudescimento da violência e da crescente atuação das organizações criminosas, faz-se necessária uma nova consciência de atuação do magistrado criminal, pautada pelo princípio da proibição de proteção insuficiente, pois o Estado-Juiz não poderá se omitir ou não adotar medidas necessárias para garantir a proteção dos direitos fundamentais do cidadão." Regime menos gravoso que o determinado, neste contexto, seria absolutamente insuficiente.

Pelas mesmas razões, não é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a concessão do "sursis".

Deveras, tais benefícios não são compatíveis, concretamente, com a necessária reprovação e a indispensável prevenção da conduta incriminada.

Afinal, como é sabido, a pena além de ressocializadora deve servir para prevenção geral e específica, de modo que a reprimenda aplicada venha a inibir a ação de outras pessoas (prevenção geral), bem como servir como repreensão ao delinquente (prevenção específica).

Assim sendo, a pena aplicada deve ser suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Em relação à possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, apesar da edição da Resolução 5/2012 do Senado Federal suspendendo a execução da expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direito" do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, baseio-me no entendimento no sentido de que o art. 44 da Lei de Drogas não está suspenso, bem como de que a proibição da substituição fia-se no art. 5º, inciso LXIII da Constituição Federal, na medida em que, mesmo se tratando de tráfico de drogas sem majorantes, a hediondez do delito não está afastada.

Não bastasse isso, é de se ter em conta que seria um verdadeiro absurdo que, concretamente, fosse a pena privativa de liberdade substituída por outra restritiva de direitos, já que isso tornaria possível que uma pessoa condenada por tal crime prestasse serviços a comunidade p.ex. em uma escola - onde fatalmente teria farta clientela - ou em um hospital, onde teria grande quantidade de substância

entorpecente muito próxima.

Por isso, com a devida vênia dos que pensam diferentemente, repudio o entendimento de que, a não ser em casos específicos e isolados, tal substituição seja possível, ainda quando a quantidade de pena concretamente imposta não seja suficiente para afastar o benefício.

Ademais, impossível, igualmente, a fixação de valor mínimo a ser ressarcido pelo réu à vítima, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, pois não há informação nos autos sobre eventuais prejuízos financeiros experimentados pela sociedade.

Se a providência já não foi deferida, autorizo, agora, a destruição da droga apreendida.

Nos termos do artigo 91, II, "b", do Código Penal e do artigo 63 e seguintes da Lei 11.343/06, decreto o perdimento dos objetos e do numerário apreendidos, se o caso.

Diante da absolvição, o veículo do réu EDEGAR, se ainda apreendido, deverá ser liberado imediatamente. Diligencie-se.

Oportunamente, diligencie a serventia para comunicação ao Funad a respeito dos bens declarados perdidos nos autos, com a ressalva acima, nos termos do artigo 63 e seguintes da citada Lei.

Nego ao réu JHONATHAN o direito de recorrer em liberdade, pois presentes os fundamentos da prisão cautelar, conforme já manifestado na decisão que determinou a prisão preventiva do réu, cujas razões tomo por empréstimo, uma vez não se verifica alteração do quadro probatório que motivou a segregação preventiva e porque ainda estão presentes circunstâncias de fato e de direito necessárias para manutenção da prisão.

Ademais, na esteira da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, "a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal" (AgRg no RHC 116.112/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª T. STJ, DJe 10/12/2019).

O réu EDEGAR poderá recorrer em liberdade, pois absolvido. Expeça-se alvará de soltura ou contramandado de prisão, conforme o caso.

Nome no rol, oportunamente.

Ao defensor nomeado, fixo honorários no máximo da tabela, expedindo-se certidão, oportunamente.

Custas "ex lege".

P.I.C.

Itapecerica da Serra, 16 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À

MARGEM DIREITA